

SENTENCIA N° 202

CÓRDOBA, 24/11/2023

En el día de la fecha, conforme lo establecido en los Acuerdos Reglamentarios N° 1622, Serie “A” del 12/04/2020 y N° 1629, Serie “A” del 06/06/2020, se dicta la presente resolución en estos autos caratulados **“REYNA, EMILIA ANGELICA C/ CONIFERAL S.A. - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJ.- ACCIDENTES DE TRANSITO” (EXPTE. N° 9274903)**, traídos con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora, la demandada CNIFERAL SACIF y la Citada en Garantía, todos en contra de la Sentencia N° 191 del 30/10/2022 dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia y 12° Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad, en cuya parte resolutive se dispone:

“I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por la Sra. Emilia Angélica Reyna D.N.I. 10.773.831 y, en consecuencia, condenar a la demandada Coniferal S.A.C.I.F., Cuit 30-54662890-2, a abonar a la actora en el plazo de diez días de quedar firme la presente resolución, la suma de pesos doscientos dos mil trescientos cuatro con cincuenta y un centavos (\$202.304,51) integrada por: \$8.629,85 Gastos de traslado, médicos y de farmacia y \$193.674,665 de incapacidad vital sobreviniente, con más los intereses fijados en cada uno de los considerando respectivos, todo ello a raíz del accidente de tránsito acaecido el día 25/10/2018.

II.- Hacer extensiva la condena a la aseguradora “Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros” en los términos del art. 118 de la ley 17.418 y en la medida del seguro.

III.- Imponer las costas en un 60% por ciento al demandado y a su citada en garantía, y en un 40% por ciento a la actora.

IV.- Regular, en forma definitiva, los honorarios del Dr. Pablo Nicolás Quiroga, en la suma de pesos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y uno con ochenta centavos (\$99.481,80— 20 jus) con más la suma de pesos catorce mil novecientos veintidós con veintisiete centavos (\$14.922,27— 3 jus) en virtud de lo dispuesto por el Art. 104 inc. 5 del C.A. Regular, de manera definitiva y en conjunto y proporción de ley, los honorarios profesionales de los Dres. Santiago Pedernera y

Marcelo Augusto Montenegro en la suma de pesos ciento cuarenta y siete mil ochenta con catorce centavos (\$147.080,14). Regular, de manera definitiva, los honorarios del Dr. Enrique Martínez Paz en la suma de pesos ciento cuarenta y siete mil ochenta con catorce centavos (\$147.080,14). En todos los casos con más I.V.A. si correspondiere al momento de su efectivo pago. Regular, de manera definitiva, los honorarios de los peritos oficiales Francisco José González y Santiago Bruno Moine en la suma de pesos setenta y cuatro mil seiscientos once con treinta y cinco centavos (\$74.611,35 —15 jus) a cada uno de ellos. Regular, de manera definitiva, los honorarios de los peritos de control Ezio Nogario y Eduardo Ciacchi en la suma de pesos treinta y cuatro mil ochocientos dieciocho con sesenta y tres centavos (\$34.818,63- 7 jus) a cada uno de ellos. En cada caso con más el porcentaje correspondiente al aporte jubilatorio conforme lo establece la ley que regula su ejercicio e I.V.A. en caso de corresponder al momento de su efectivo pago.

PROTOCOLICESE Y HAGASE SABER”.

Texto Firmado digitalmente por: LINCON Yessica Nadina, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA,
Fecha: 2022.10.31.

Seguidamente el Tribunal fijó las siguientes cuestiones a resolver: **Primera cuestión: ¿Procede el recurso de apelación interpuesto? Segunda cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?**

Conforme el sorteo oportunamente realizado los Señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dr. Federico Alejandro Ossola y Dra. Viviana Siria Yacir.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DR. FEDERICO

ALEJANDRO OSSOLA DIJO:

I.- LO ACTUADO EN ESTA SEDE.

Llegados los autos esta Cámara, la parte actora expresó agravios con fecha 07/07/2023, los que fueron contestados por la demandada el 08/08/2023 y por la Citada en garantía el 24/08/2022.

El mismo día las dos restantes apelantes desistieron de sus recursos, solicitando imposición de costas por el orden causado, lo que fue consentido por la actora mediante presentación del 05/09/2023.

La Sra. Fiscal de Cámaras evacuó el traslado corrido, con motivo del art. 52 de la ley 24.240, con fecha 02/10/2023.

Cumplimentados los demás trámites de ley, queda el recurso en estado de ser resuelto.

II- EL DESISTIMIENTO.

La demandada CONIFERAL S.A. y la Citada en Garantía MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS con fecha 24/08/2023 desisten del recurso de apelación interpuesto, a lo que la actora presta su conformidad.

En consecuencia, y por no encontrarse involucradas normas de orden público, corresponde tener presente y admitir el desistimiento de la demandada CONIFERAL S.A. y la Citada en Garantía MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS del recurso de apelación interpuesto por ambas en contra de la Sentencia N° 191 del 30/10/2022 dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia y 12° Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad.

Asimismo, corresponde no imponer costas por los recursos de apelación desistidos, conforme criterio ya sentado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia de esta provincia (entre otros, “Fisco de la Provincia de Córdoba c/ Nelson José A. Vagliente y otros - Ejecutivo - Recurso de casación”, Auto N° 395 del 21/10/2011, “Berrotarán, José Ignacio c/ Soler Sánchez S.R.L. y otro - Ordinario - Recurso directo”, Auto N° 79 del 09/05/2002), el que se adopta por razones de economía procesal dejando a salvo el criterio sustentado por esta Cámara.

II.- EXPRESIÓN Y CONTESTACIÓN DE LOS AGRAVIOS.

1.- La expresión de agravios.

La Sra. REYNA se agravia por dos cuestiones.

En su **primer agravio**, dice que cuestiona la **reducción indemnizatoria y la tasa interés**.

Señala que la A Quo luego de realizar un análisis de la prueba obrante en autos, donde se establece que los extremos fácticos relatados por actora fueron veraces y que la responsabilidad por los daños en la salud de la víctima debe de adjudicársele a los demandados en autos, efectúa un desarrollo de los rubros reclamados hasta abordar el tópico que su parte denominó pérdida de la capacidad vital sobreviniente.

Luego de transcribir lo señalado por la sentenciante, afirma que ella realizó un reclamo basado en las consecuencias dañosas en su salud que fueran resultado de un accidente vial mientras viajaba en el transporte público de pasajeros concesionado por la demandada. A raíz de ello se reclamó, entre otros, el rubro de la “pérdida de la capacidad vital sobreviniente de la actora”, el cual fue receptado por el juzgador, pero con matices que desvirtúan el sentido que esta parte quiso otorgarle.

Dice que no ha reclamado “daño consecuencia”, sino “daño lesión”, ya que la lesión a la capacidad vital de las personas se ubica dentro del daño-lesión y se apunta a no solo tutelar la cesación de utilidades sino a tutelar un amplio abanico de actos cotidianos que cubren necesidades, proporcionan servicios o brindan bienestar a sí mismo, como en el caso de autos donde la actora probó su limitación funcional, problemas de locomoción y para realizar actividades cotidianas debido a las lesiones sufridas (véase pericia médica oficial) y, como surge de la pericia psiquiátrica efectuada, la misma no podrá realizar actividades como alzar sus nietos o caminar con normalidad.

Debe advertirse que el daño se produjo dentro de una unidad de transporte urbano de pasajeros los cuales eran de uso cotidiano de la actora y en la actualidad son de muy difícil utilización por parte de ella debido a sus limitaciones para desplazarse.

La sentenciante recepta el reclamo impetrado por esta parte, pero realiza una reducción al monto obtenido de la fórmula empleada por considerar que la pérdida de la capacidad vital sobreviniente debe englobarse dentro de una pérdida de chance futura y no dentro del lucro cesante, cuestión agravante para la suscribiente.

Afirma que, respecto a tales rubros, Pizarro y Zavala de González, han sostenido que no existe una diferencia ontológica entre tales la incapacidad sobreviniente y el lucro cesante, pues siempre se

trata de la pérdida de ingresos, antes o después de la consolidación de las lesiones, o del fin de la etapa curativa.

En ningún caso se resarce el menoscabo a la integridad del sujeto en sí mismo, en tanto se trata de un bien (el cuerpo humano) que no está en el comercio, por lo que las lesiones a la salud o a la integridad corporal, solo pueden derivar en daño moral o patrimonial.

Lo explica Matilde Zavala de González al decir que "las consecuencias materiales o económicas atinentes a los llamados lucro cesante e incapacidad no varían en lo fundamental, de modo que no hay verdadera diferencia – esencial u ontológica – entre esos rubros en lo que hace al daño mismo. En ambos casos nos hallamos ante un lucro cesante, solo que en la primera hipótesis éste se conecta con la etapa terapéutica y hasta el momento del restablecimiento, y en la segunda hipótesis se atiende a secuelas no corregibles sino luego de un mayor plazo (incapacidad transitoria) o bien no subsanables en modo alguno (incapacidad permanente)"

En igual sentido, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (La Ley 1975-C-87) tiene posición tomada en cuanto a la clasificación del daño, en el sentido de que el daño es la consecuencia de la lesión, y que si bien se han producido lesiones incapacitantes, el daño que se indemniza es la consecuencia de aquellas lesiones en el ámbito material o moral, por lo que –a nuestro modo de ver – carece de autonomía todo otro daño (Zavala de González, Matilde, "Resarcimiento de daños, V.2a, Daños a las personas. Integridad psicofísica", pags. 191 y sgts.).

Expresamente se ha dicho que la incapacidad sobreviniente alude la "inhabilidad o impedimento o bien la dificultad apreciable para el ejercicio de funciones vitales" (Matilde Zavala de González, "Daños a las personas", tº2 a, p. 281, 2da edición ampliada, 4ta reimpresión, Ed Hammurabi). Se trata una afectación negativa de facultades y aptitudes que gozaba la víctima antes del hecho dañoso, cuya reparación procede en defensa del derecho subjetivo a la integridad personal como "complemento necesario del mismo derecho a la vida." (Eduardo Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", Ed Astrea, p. 156 nota 62).

Por eso, entre los derechos de la personalidad se encuentra en primer lugar "la preservación de la integridad física, psíquica y moral del hombre", cuya tutela tiene raigambre constitucional, y en los tratados con jerarquía constitucional incluidos como complementarios de los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional (art.75 inc.22).

Tiene por finalidad no solo dar cobertura a las limitaciones de orden laboral, sino también a la proyección que la secuela provoca con relación a todas las esferas de la personalidad del lesionado, concentrando aspectos como la disminución de su seguridad, reducción de su capacidad vital –como por ejemplo no poder desarrollar ciertos deportes y/o despliegue de vida al aire libre. En definitiva, todo aquello que conduzca al empobrecimiento de las perspectivas futuras de la víctima. La incapacidad no solo debe medirse en el aspecto del trabajo, sino también, en cuanto atañe a las actividades de la víctima y la proyección que tiene el accidente sobre la personalidad integral. Cabe valorar la forma en que la lesión gravita en otros aspectos de la personalidad de la víctima: domésticos, deportivos, culturales, estéticos, sociales, etc., que en la medida que afecten el desarrollo pleno de la vida de esta, son susceptibles de ser tenidos en cuenta al margen de lo que se otorgue en otro concepto objetivamente.

Así mismo, si tenemos en cuenta los parámetros de ponderación para determinar la reducción de la incapacidad, resulta un tanto prejuiciosa y discrecional la postura del Tribunal de primera instancia, ya que toma en cuenta que la edad de la persona como si un sujeto de avanzada edad no tuviese los mis derechos a una vida plena (por el tiempo que fuese) y en iguales condiciones que previo a tener el accidente, como alguien más joven. No se puede cotizarse más la pérdida de beneficios o cumplimiento de actividades de una persona sobre la otra, por solamente la edad, capacidad productiva o el nivel de ingresos. Da por sentado que su estado de salud, previo al accidente, también le impedía la realización de las tareas que hoy se probaron que no puede realizar, pero no surge de ninguna probanza de autos que previo al accidente haya tenido dificultades como las que presente hoy, ello solo es una presunción del a quo. El resto de las ponderaciones solo hace

confirmar la postura de la recepción por parte del Tribunal de la indemnización por la incapacidad sobreviniente.

En virtud de lo manifestado solicita se haga lugar al presente recurso y revoque parcialmente el fallo de Primera instancia en cuanto a la reducción de la suma indemnizatoria y otorgue el cien por ciento de la misma, con más sus respectivos intereses. Subsidiariamente para el caso que esta Cámara considere que corresponda una reducción del monto indemnizatorio, solicita que el mismo no sea más del 20% del mismo ya que no existe un parámetro certero que así lo justifique.

Como **segundo agravio** dice que se agravia de la **imposición de costas**.

El Fallo del a quo al expresarse sobre las costas del presente proceso manifiesta: “(...) En este sendero, el monto favorablemente acogido equivale al 23% del monto peticionado, estimo prudente distribuir las costas en un 60% a los demandados Coniferal S.A.C.I.F. y Mutual Rivadavia de Seguros del transporte público de pasajeros y en un 40% al actor, teniendo en cuenta asimismo que litiga con beneficio concedido conforme Expte N° 9279075 (cfr. Auto N° 380 del 21/09/2021)”. Independiente que la actora intervenga en el proceso con Beneficio de Litigar sin Gastos, cabe señalar que el art. 130 del C.C.P.C. establece que las costas deben aplicarse al perdedor salvo expresa justificación del magistrado, pero en el caso de autos dicho apartamiento a la norma no viene acompañado de la debida y necesaria fundamentación que exige e impone la misma.

Hay que tener en cuenta que la condena en costas comprende todos los gastos que el litigante debió hacer para el reconocimiento de su derecho, es decir, gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso. Las costas no revisten el carácter de pena sino de indemnización debida a quien injustamente se vio obligado a efectuar erogaciones judiciales. Es decir, comprende los gastos ocasionados al oponente por obligarlo a litigar, con prescindencia de la buena o mala fe o de la razón de las partes, pues para la teoría objetiva de la derrota, la conducta de aquéllas o el aspecto subjetivo es irrelevante.

La regla general impone a la parte vencida el deber de pagar todos los gastos realizados por la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho, y en el caso de autos no se llevaron adelante

erogaciones por el simple hecho de que se obtuvo favorablemente el Beneficio de litigar sin gastos, que de no estar este último si los debería haber afrontado. El a quo da a entender que la aplicación de costas solo la realiza de esa manera por la existencia del mencionado beneficio dando a entender que la resolución hubiese sido otra si no estaba. Téngase presente que para apartarse del principio objetivo de la derrota debe tener una adecuada fundamentación pero en el caso de marras la actora consiguió probar los extremos facticos invocados y fueron admitidos los rubros solicitados, que si bien uno de ellos en menor cuantía a los previsto, no queda en duda que la actora se vio obligada a litigar en defensa de sus derechos ante una situación disvaliosa que provocó una merma considerable en su estado de salud psicofísico.

La imposición de costas debe meritarse de manera prudente y reflexiva en cada caso particular el contexto del proceso, para concluir acerca de la procedencia de la decisión judicial de apartarse del principio general, para evitar sortear indiscriminadamente la pauta genérica establecida legalmente. No puede olvidarse que el fundamento del principio del cual estamos hablando está determinado – siguiendo a Chiovenda - por la necesidad de servirse del proceso para obtener la razón; lo cual no debe volverse en contra de quien la tiene.

La teoría del vencimiento, para la imposición de la condena al pago de las costas, no atiende a elementos subjetivos, como el dolo o la culpa, sino al hecho objetivo del vencimiento.

Chiovenda le adjudicó dos notas características a la teoría, la primera es que la condena en costas no está subordinada ni a la temeridad ni a la culpa del vencido, pues solo requiere la condición objetiva del vencimiento. La condena en costas responde al hecho objetivo de la derrota, no por ser temerario o como sanción a la mala fe o inconducta procesal.

En virtud de lo manifestado solicita se revoque la sentencia en cuanto a la aplicación de costas y cargue las mismas a la demandada en un cien por ciento.

2.- Las contestaciones.

Amas apeladas sostienen la decisión de la sentenciante, y piden se confirme lo resuelto.

Señala la accionada que no se trata de una valoración en desmedro de la actora por su condición de jubilada y su avanzada edad, sino que la reparación del daño en base a su extensión, no puede ser la misma para una persona que no demostró sufrir mermas en sus ingresos o afectación patrimonial por la no realización de sus quehaceres domésticos, que aquella que sí lo sufrió. No resulta igual para una persona joven en plenitud física con toda una vida por delante y de proyección, que para aquella persona de avanzada edad y con limitaciones físicas que por estadística y el orden natural, no cuenta con la misma expectativa y proyección de vida. Tampoco resulta idéntica la reparación del daño para quien sufre un daño con una alta incapacidad (ej. 45% o 60% o se le amputa una pierna como en el caso “Dutto”), que para aquél que tiene – como en el caso de autos- una incapacidad dictaminada del 10%, con afecciones preexistentes por artrosis.

Pide se aplique el art. 132 del CPCC, confirmándose lo decidido.

La Citada en garantía, en su presentación, adhiere a lo peticionado por la demandada.

III.- EL PRIMER AGRAVIO.

1.- Lo reclamado en la demanda.

Conviene transcribir lo que el actor solicitó por este rubro:

“a) Pérdida de capacidad Vital:

El resarcimiento por pérdida de la capacidad vital refiere al derecho de la víctima a ser reparado íntegramente por el daño causado. Esta reparación está relacionada con la pérdida de ventajas o privación de beneficios que, si bien tienen trascendencia económica y patrimonial, están estrechamente vinculados con el ejercicio de funciones vitales, la vida en relación y el goce en pleno de la persona.

Nuestra Corte Suprema ha dicho que cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas psíquicas en forma permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación, al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y por daño moral, ya que la integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable y su cesión comprende diversos aspectos

de la personalidad que hacen en el ámbito doméstico y cultural o social con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida.

Con la sanción del art- 1746 del C.C.C.N. se ha desterrado el criterio reduccionista que pretendía considerar al ser humano como un objeto, sobre la base de un visión economicista de la vida, para tomarlo como un sujeto de derecho, un ser humano, complejo y único, que merece una reparación plena frente la universalidad de perjuicios que es pasible de sufrir.

Lo que se busca en este caso es una indemnización integral por los daños sufridos en la persona de la Sra. Reyna, no importando para ello si la misma trabaja o no, si es jubilada o pensionada, etc.

Cálculo:

INCAPACIDAD - Formula Marshal /Las Heras - Requena Edad 65 Diferencia 7

Coeficiente según tabla de Interes Anual al 6 % = 5,5824 Vida Util 72 Sueldo: 25132

% Incapacidad: 45 Empleado 13 Autonomo 12 $C = a * b$ a: 155843,532 b: 5,5824

$a = (\text{sueldo} \times 12 \text{ o } 13 \text{ si es trab en relac de dependencia}) \times 1,06$ que es el monto anterior más un interés puro a título de productividad del capital.

$b =$ se saca el coeficiente de la tabla. Monto Indemnizatorio \$ 869.980,93

Se reclama incapacidad sobreviniente por pérdida de la capacidad vital la suma de pesos ochocientos sesenta y nueve mil novecientos ochenta con 93/100 (\$869.980,93)".

2.- Pauta inicial.

Como surge claramente del texto de la demanda, y se reitera (incluso explícitamente) en la apelación -aunque con varias contradicciones, citándose incluso autores que participan de la posición opuesta a la que adhiere la actora-apelante-, lo que se solicita es la reparación **de la lesión en la integridad psicofísica de la actora, y no la indemnización de un daño resarcible que no es sino la consecuencia de la lesión a un bien jurídico de titularidad del damnificado.**

3.- Bases conceptuales.

a.- La distinción entre daño —concepto amplio— y daño resarcible —concepto estricto— ha generado enormes contrapuntos en la doctrina y la jurisprudencia, y con una importantísima

repercusión práctica: no son pocos quienes postulan que, además del daño patrimonial y del daño moral (o extrapatrimonial, como ahora se lo llama en el Cód. Civil y Comercial), existen otros daños que deben también ser resarcidos, como el daño “biológico”, el “estético”, el “psicológico”, el “daño al proyecto de vida”, etcétera.

En mi opinión (y siguiendo a parte importante de la doctrina y jurisprudencia), *en el Cód. Civil y Comercial se distingue entre “daño” en sentido amplio (como lesión a un derecho o a un interés no reprobado por el ordenamiento — art. 1737 del Cód. Civil y Comercial—) y el “daño resarcible”, que está constituido por las consecuencias de la lesión (arg. arts. 1726, 1727, 1738, 1740 y 1741 del Cód. Civil y Comercial) y tiene dos especies: el daño patrimonial y el daño moral, no admitiendo otros géneros diferentes.*

El objeto de la prevención es el *peligro de daño*, entendido tal concepto *en sentido amplio*, esto es, en los términos en que se encuentra definido en el art. 1737 del Cód. Civil y Comercial; el objeto de la reparación, lo que se indemniza, es el *daño resarcible*; esto es, las *consecuencias* de la lesión, y no esta última en sí misma.

De todas maneras, es importante advertir que la letra de la ley no es diáfana en varios pasajes, lo cual podría habilitar una interpretación acorde a la postura que sostiene la existencia de los denominados “terceros géneros”, y que rechazo, por su improcedencia sustancial.

Es que el concepto de *daño resarcible* tiene un amplísimo rango de alcance: debidamente calibrado, permite la reparación de *todas y cada una* de las consecuencias perjudiciales causalmente derivadas de un suceso dañoso, siempre que se encuentren dentro del abanico de consecuencias resarcibles que el ordenamiento prevé, en cuanto regla general en el art. 1726 del Cód. Civil y Comercial (se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles), y en particular para ciertos supuestos (sea que la indemnización sea de mayor o menor extensión que en el caso de la regla general).

b.- El concepto de daño y de daño resarcible en nuestro ordenamiento ha sido objeto de una profunda polémica, con sutiles e importantes matices según los autores y los fallos de quienes han

adherido a los postulados de cada corriente, y con una directa incidencia, de la más alta trascendencia: la determinación de los rubros indemnizables y de la cuantía de la indemnización es una directa derivación de la postura que se adopte al respecto.

El daño como lesión a un bien jurídico o a un derecho subjetivo. Como lo señala De Cupis, desde una muy amplia perspectiva, “daño” es “nocimiento o perjuicio, es decir, minoración o alteración de una situación favorable” (Adriano DE CUPIS, *El daño*, 2.^a ed. italiana trad. por Ángel Martínez Sarrión, Barcelona, Bosch, 1975, p. 1). Se trata de una *cuestión fenomenológica*, que en el *Diccionario de la lengua española*, está definido como el efecto de “dañar”, o sea ‘causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia’ (acepción 1.^a) y ‘maltratar o echar a perder una cosa’ (acepción 2.^a). Pero, además de ser un fenómeno físico, este “daño” puede integrar un fenómeno jurídico, es decir, susceptible de ser jurídicamente calificado. El ordenamiento *reacciona ante el daño* de las más diversas maneras, según cuáles sean los intereses jurídicos que se encuentren en juego, imponiendo a los responsables de tal situación deberes jurídicos o sanciones de la más diversa índole.

La doctrina tradicional entiende que el daño se configura con *el menoscabo a un bien jurídico o la lesión a un derecho subjetivo patrimonial* (generando daño patrimonial) o *extrapatrimonial* (generando daño moral) (Entre otros, véanse Karl LARENZ, “Derecho de Obligaciones”, en *Revista de Derecho Privado*, 1952-I, p. 193, Madrid; Roberto H. BREBBIA, *El daño moral*, Rosario, Orbir, 1967, pp. 57 y sigs.; Arturo ACUÑA ANZORENA, “La reparación del agravio moral en el Código Civil”, en *La Ley*, 16, p. 536); e, incluso, en sentido más amplio aún, con la violación misma del ordenamiento.

Indica Orgaz que, con esta acepción, por definición todo acto ilícito debe producir daño: “la acción u omisión ilícitas entrañan siempre la invasión en la esfera jurídica de otra persona, y con este primer efecto, común a todo supuesto de ilicitud, cabe afirmar que esta persona sufre un daño que obliga al autor al restablecimiento de la situación conforme a derecho” (Alfredo ORGAZ, *El daño resarcible*, Córdoba, Lerner, 1980, p. 14).

Nuestra mirada se centra ahora en la *reparación* de los daños. Desde dicha perspectiva, esto es, desde la *responsabilidad civil*, esta concepción primaria —si bien necesaria— luce insuficiente y ha sido pasible de fundadas críticas.

Esencialmente, se le cuestiona que de la lesión a un bien de naturaleza patrimonial puede surgir daño moral (por ej., el grave deterioro en un inmueble producido por filtraciones de agua derivadas del lindero, que provoca en sus habitantes un serio desasosiego espiritual, preocupaciones, merma en su calidad de vida, etc.) y, a la inversa, de la lesión a un bien extrapatrimonial puede producirse daño patrimonial (por ej., la lesión a la integridad psicofísica de una persona, que le genera incapacidad laborativa).

Es que “la idea de daño como simple menoscabo a un bien —en el más puro sentido naturalístico, diríamos— es inadecuada, dado que esa idea debe enlazarse inexorablemente con un *quid juris*” (Alberto J. BUERES, *Derecho de daños*, Buenos Aires, Hammurabi, 2001, p. 285).

Ahora bien, y como lo expone Bueres, “tampoco parece de recibo la tesis de aquellos que creen que el daño es la lesión a un derecho subjetivo”, ya que es pasible de la misma crítica (de la lesión a un derecho subjetivo patrimonial puede derivarse un daño moral, y viceversa), además de que el daño no se califica por la lesión a un bien o a un derecho, sino que el perjuicio adviene debido a que los bienes o los derechos lesionados satisfacen *necesidades* o *intereses* que aquellos proporcionan al damnificado (pp. 286/287).

En sentido coincidente, Calvo Costa agrega que entiende “incorrecta la postura de sostener que el daño es una lesión a un derecho subjetivo, puesto que defender la misma implica desde ya descartar la existencia de simples intereses que pueden ser relevantes jurídicamente, o incluso de intereses colectivos, tan en boga en estos tiempos. El interés simple, aun cuando no esté revestido de juridicidad en forma específica, sí lo puede estar en forma genérica y —de ser así— debe ser atendido a los fines resarcitorios” (Carlos A. CALVO COSTA, *Daño resarcible*, Buenos Aires, Hammurabi, 2005, p. 68).

Desde otra mirada, cabe apuntar que en el *análisis económico del derecho*, los daños representan desventajas sociales y pérdidas de utilidad por el solo hecho de ocurrir, y con independencia de su resarcimiento: la pérdida ya se produjo para la sociedad y, desde esta perspectiva, es irreparable. El objetivo esencial del análisis económico del derecho, es evitar o aminorar en lo posible la producción de daños, que no solo comprende el menoscabo directo del bien perdido, sino las consecuencias (costos) que se derivan de aquel detrimento (gastos, honorarios, etc.) (Luis DIEZ-PICAZO, Derecho de Daños, pp. 208 y sigs.).

El daño como lesión a un interés legítimo. Para otra corriente, de fuerte predicamento en nuestro ámbito, el daño consiste en la lesión a un *interés jurídicamente tutelable*, reconocido o no de manera explícita por el derecho, pero no reprobado por el ordenamiento. Zannoni indica que el damnificado, al exigir la reparación, opone “un interés patrimonial o extrapatrimonial —moral— que ha sufrido lesión, agravio. Pero, para que pueda decirse que existe un interés lesionado o agraviado, es menester que quien se dice damnificado demuestre que el menoscabo afecta, imposibilita, en su esfera propia, la satisfacción o goce de bienes jurídicos (en sentido lato) sobre los cuales ejercía una *facultad de actuar*. Esta facultad de actuación en la esfera propia del damnificado constituye su interés: el daño ha lesionado ese interés” (Eduardo A. ZANNONI, El daño en la responsabilidad civil, 2.^a ed., Buenos Aires, Astrea, 1995, pp. 50/51).

Bueres —en sentido coincidente— agrega que “la conexión entre los bienes —o los derechos que tienen por asiento esos bienes— se realiza por el rasero de los intereses. Verdaderamente el *quid* es la lesión al interés, pues aunque dicha lesión provenga del menoscabo de bienes —o a derechos— lo real es que ella (la lesión al interés) —como afirma Ravazzoni— se ajusta más y mejor a la manera como debe apreciarse el daño en su realidad concreta y subjetiva” (Alberto J. BUERES, Derecho de daños, cit., p. 288).

Así, en el caso de la lesión al honor (bien de naturaleza jurídica extrapatrimonial), el daño es la lesión de los distintos intereses jurídicos que *reposan* sobre ese bien: los patrimoniales y los extrapatrimoniales, y que son el núcleo esencial de la tutela jurídica.

Advierte Pizarro que existen importantes diferencias en orden al alcance del concepto de *intereses extrapatrimoniales*, ya que algunos le asignan mayor extensión que otros (respecto de si comprende o no intereses estrictamente espirituales, o de otra índole) (Ramón D. PIZARRO, Tratado de la responsabilidad objetiva. Tomo 1, Buenos Aires, La ley, 2015, p. 155).

Doctrina que distingue entre el “daño” en sentido amplio y el “daño resarcible” en cuanto consecuencia de la lesión a un interés. Para una tercera posición, el daño no se identifica con la lesión al interés, sino que, partiendo necesariamente de dicha lesión, *el “daño resarcible” está constituido por la totalidad de las consecuencias o repercusiones perjudiciales o disvaliosas, en concreto, derivadas de dicha lesión* (Alfredo ORGAZ, El daño resarcible, cit., p. 18; Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ, Resarcimiento de Daños. 4. Presupuestos y funciones del derecho de daños, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, pp. 117 y sigs.; Ramón D. PIZARRO y Carlos G. VALLESPINOS, Instituciones de derecho Privado. Obligaciones. Tomo II, cit., pp. 639 y sigs.).

Conviene transcribir el pensamiento de Orgaz, quien fue el que elaboró con claridad este pensamiento, sobre la base de importantes antecedentes, constituyendo el punto de partida de esta concepción. Su análisis partía del art. 1068 del Cód. Civil, en el que se disponía que “habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, o *directamente* en las cosas de su dominio o posesión, o *indirectamente* por el mal hecho a su persona o a sus derechos o facultades”. La bastardilla pertenece al autor, quien luego indica: “a menudo se caracteriza el daño material diciendo que es el ataque a los derechos patrimoniales, y el daño moral, el ataque a los derechos extrapatrimoniales. Esta caracterización es, a nuestro juicio, errónea: la distinción no depende de la índole de los derechos que son *materia* del acto ilícito, sino de la repercusión que este acto tiene en el patrimonio. La lesión a un derecho patrimonial puede ocasionar no solamente un daño material, sino, también, uno moral, en cuanto moleste a la persona ‘en el goce de sus bienes’ (como decía el art. 1078) o de sus derechos; del mismo modo, el ataque a un derecho no patrimonial —v.gr. el honor— puede producir, y a menudo produce, no solamente un perjuicio moral sino, también, uno material, si el desprestigio o la deshonra del afectado determina

la frustración de beneficios económicos esperados (pérdida de un contrato, etc.)” (Alfredo ORGAZ, El daño resarcible, cit.,p. 18).

Este fue el puntapié inicial que luego Zavala de González y Pizarro afinaron y calibraron en función de los avances ideológicos y normativos que la responsabilidad civil fue experimentando.

La primera señaló que “el daño versa sobre el ‘*resultado*’ de la lesión a un bien o a un interés jurídicos; es decir, se distingue entre la lesión y las consecuencias perjudiciales que de ella se derivan. La lesión es el evento fáctico disvalioso inherente a un suceso: la destrucción de un vehículo en un accidente, la muerte que infiere el homicida [...] En cambio, y técnicamente, el *daño* se integra por todas *las repercusiones perjudiciales* de dicho evento lesivo [...] si lo que decidiese la existencia y magnitud del daño fuesen el bien o el interés violados, la indemnización debería ser más o menos uniforme para cada especie de lesión. Por ejemplo, la vida o la integridad física de un hombre valen tanto como la de otro cualquiera. *Sólo apreciando las repercusiones en cada caso, conforme con las circunstancias del hecho y de la víctima, es factible conceder una reparación apropiada e individualizada*” (Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ, Resarcimiento de Daños. 4. Presupuestos y funciones del derecho de daños, Ed. Hammurabi, 2001, Buenos Aires, pp. 118/119). Se postula, pues, que es conveniente (y necesario) distinguir entre daño *en sentido amplio* (el *daño-lesión*) y *daño resarcible* (el *daño-consecuencia*), siendo este último el que hay que indemnizar. *De allí la trascendencia de señalar que el daño resarcible es el efecto (consecuencia) de la lesión al interés.*

Se trata de una cuestión *netamente causal*: media entre el *daño-lesión* y el *daño-consecuencia* una relación de “causa-efecto”, y el segundo requiere de la previa existencia del primero.

Es claro, entonces, que la lesión al interés es un elemento *necesario*, una *conditio sine qua non*, pero no se identifica con el “daño resarcible”, el que se constituye con *la incidencia concreta del menoscabo —económico o espiritual— en la existencia de la víctima.*

Pertinencia conceptual de la distinción entre “daño-lesión” y “daño-consecuencia”. Sin perjuicio de que entiendo que se ha recogido en el Cód. Civil y Comercial la distinción entre *daño-*

lesión y daño-consecuencia, siendo este último el verdadero *daño resarcible*, soy de la opinión de que es esta postura la que responde adecuadamente a la naturaleza de las cosas, y brinda las respuestas más satisfactorias y coherentes.

Es claro, como lo señala Calvo Costa, que las teorías del *daño-lesión* a un interés y del *daño-consecuencia* no se contradicen, sino que son *complementarias*. Es que “la plataforma de partida debe ser el interés, puesto que cuando el intérprete y/o el legislador seleccionan los daños resarcibles aprecian para ello el interés del sujeto. Recién en una segunda instancia, a la hora de fijar el resarcimiento, sí se deben apreciar las consecuencias (definir el *quantum* a indemnizar), ya que con la sola mención de que se ha lesionado un interés protegido no basta” (Carlos A. CALVO COSTA, *Daño resarcible*, cit., p. 94).

Pero, en mi opinión, no se trata simplemente de un *quantum*, sino de algo más: la consecuencia es —por una cuestión de lógica elemental— de la misma naturaleza que el interés afectado.

Pero la *proyección en concreto* de la lesión al interés no se identifica con este, sino que *integra* la consecuencia.

Así, luego de establecida dicha consecuencia en lo *cualitativo* (lo que comúnmente se denomina la *valoración* del daño), corresponde determinar *cómo* se indemniza, sea mediante la reparación en especie o bien mediante la entrega de una suma de dinero, generándose una obligación de tal naturaleza (lo que se establece mediante la operación de *cuantificación* del daño).

Esta postura tiene un mérito indiscutible: *evita duplicar las indemnizaciones*, esto es, otorgar diferentes resarcimientos, bajo ropajes jurídicos *diferentes*, pero que en rigor de verdad corresponden *a lo mismo*.

En el afán, en ciertos casos desordenado y algo desajustado en lo conceptual, de reparar *todo* daño, se corre el serio riesgo de mandar a pagar dos o más veces el mismo rubro o concepto, generando un indiscutible *enriquecimiento sin causa* a favor de la víctima.

La *reparación* del daño, en sentido jurídico (y siempre en el límite de las consecuencias resarcibles) no coloca a la víctima en una mejor situación que la que se encontraba antes del suceso dañoso, sino que debe dejarla *indemne*; esto es, como si el suceso no hubiera ocurrido.

Si, por ej., por una seria lesión estética en el rostro de una persona que realiza actividades productivas con su imagen (por ej., un actor profesional o una modelo) se mandara a reparar todo el lucro cesante y todas las pérdidas de chances productivas que experimentó, además del daño moral y los gastos de tratamientos médicos y curaciones, *adicionándose* la indemnización del *daño estético*, es por demás evidente que este último rubro carecería de contenido, y se estaría poniendo un “valor” a la lesión en sí misma.

La cuestión, pues, transita por apreciar adecuadamente los *conceptos*, tanto de daño *resarcible* patrimonial como de daño *resarcible* moral, *a la luz de lo que se dispone en nuestro ordenamiento*.

No existe, pues, tipicidad alguna respecto de las consecuencias resarcibles: se reparan todas las que tienen nexo adecuado de causalidad, dentro del elenco de las *consecuencias resarcibles* en cada caso, siendo la regla general (salvo disposición en contrario) lo establecido en el art. 1726 del Cód. Civil y Comercial: se *resarcen* las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles. El *contenido* de ambos conceptos es lo suficientemente amplio y flexible para no dejar fuera de resarcimiento *todo* aquello que ha sido menoscabado.

La cuestión en el Código Civil y Comercial. La recepción de los dos conceptos de daño. En mi opinión, en el Cód. Civil y Comercial se ha plasmado un concepto *doble* de daño: el “daño” en sentido general (*daño-lesión*) y el “daño resarcible”, que es lo que se indemniza, en tanto *consecuencia* de la lesión.

Esto no es contradictorio, ni existe superposición alguna, sino *todo lo contrario*: en cada caso tienen un rol específico.

La Comisión que elaboró el Anteproyecto señaló —luego de pasar revista a la discusión sobre el tópico— que se “*distingue entre daño e indemnización* sobre la base de los siguientes criterios: el daño causa una lesión a un derecho o a un interés que no sea contrario al ordenamiento. Cuando ese

derecho o interés es individual recae sobre la persona o el patrimonio, y esto significa que los derechos tienen un objeto, como se señala en el Título Preliminar. También están incluidos los de incidencia colectiva. Esta caracterización hace que distingamos entre la definición del daño-lesión y la indemnización, lo que aporta más claridad en la redacción. La responsabilidad *es uno de los instrumentos de protección de los mencionados derechos*, siendo una de sus funciones la reposición al estado anterior al hecho generador o la indemnización. Por lo tanto, *la indemnización es una consecuencia de la lesión*".

Es por demás evidente que la locución *indemnización* no puede sino referirse al *daño resarcible, en cuanto consecuencia de la lesión* (el "*daño*", en palabras de la Comisión), por más que una interpretación restringida la circunscriba al *contenido (quantum) de la obligación de dar dinero que es la indemnización*. Dicha obligación es producto de *dos operaciones* que corresponde realizar: la valoración (determinación de la entidad cualitativa) y la cuantificación (su traducción en una suma de dinero), y es por demás evidente que constituye el reflejo final de ambas, que en este punto son inescindibles.

Comentando las nuevas normas, Zavala de González indica que "el Código deslinda el daño de su indemnización (arts. 1737 y 1738). Rezeptá así la orientación que concibe al daño injusto como *lesión a un interés*, el cual es *presupuesto de responsabilidad*, y el daño como *requisito de la obligación resarcitoria*, referido a las *consecuencias* que deben repararse" (Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ, La responsabilidad civil en el nuevo Código. Tomo 2, Córdoba, Alveroni, 2015/2016, p. 489).

En sentido coincidente, Galdós, comentado el art. 1737, señala que "la norma prevé el daño-lesión que lo diferencia del daño-consecuencia; se alude a la indemnización del detrimento o menoscabo causado a una trilogía de bienes tutelados: la persona, el patrimonio y los derechos de incidencia colectiva" (Jorge GALDÓS, en Ricardo L. Lorenzetti (director), Miguel F. De Lorenzo (coordinador), Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Tomo VIII, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2015, p. 481).

Sin embargo, Alferillo indica: “no compartimos el criterio que sostiene la disgregación del daño y que sólo son resarcibles las consecuencias patrimoniales o morales, por el contrario, el menoscabo como bien dice el art. 1737 tiene por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva sobre el cual el sujeto tiene un derecho reconocido por la ley o un interés no reprobado por ella. Es decir, la definición del Código Civil y Comercial se pronuncia a favor de la unidad conceptual del daño resarcible, pues integra en su definición el objeto sobre el cual recae con el interés legítimo protegido por la ley y, también, al no contrario a la legalidad” (Pascual ALFERILLO, en Jorge H. Alterini (director general), Pascual E. Alferillo, Osvaldo R. Gómez Leo y Fulvio G. Santarelli (directores del tomo), Ignacio E. Alterini (coordinador), Código Civil y Comercial comentado. Tratado Exegético. Tomo VIII, Buenos Aires, La Ley, 2015, p. 184).

Entiendo que lo señalado por Zavala de González y Galdós es lo que se ha plasmado en la nueva normativa, en función de una interpretación armónica y sistemática de varias disposiciones que, analizadas en su conjunto, nos llevan de manera necesaria a tal conclusión.

El “daño” en sentido amplio (“daño-lesión”). En el art. 1737 del Cód. Civil y Comercial, primero en la Sección 4.^a (“Daño resarcible”), se dispone: “Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”. Como puede observarse, claramente se conceptúa al *daño-lesión* (se emplea este último término), y no al *daño resarcible*.

Se adopta una concepción amplia (como explícitamente lo señala la Comisión) que, en rigor de verdad, podría haberse circunscripto a considerar al *daño* como la lesión al *interés jurídico* que reposa sobre los bienes individuales o colectivos, pero que, de todas maneras, resulta gráfico al hacer referencia a los “derechos”.

No se trata, pues, de la lesión a un “derecho subjetivo” exclusivamente, sino del menoscabo de *cualquier* interés jurídico, en tanto y en cuanto no se encuentre expresamente reprobado por el ordenamiento; puede observarse que la referencia a los *intereses* se circunscribe a esta última cuestión.

Se cierra así el debate respecto de la tutela de los denominados *intereses de hecho*; esto es, aquellos no reconocidos, pero tampoco repudiados por el ordenamiento, que aquí quedan *equiparados*, a los efectos del *daño jurídico*, sin perjuicio de sus diferencias sustanciales.

No habrá, pues, daño jurídico si la lesión se produce en un interés que el ordenamiento rechaza como digno de la tutela jurídica; por ej., el menoscabo patrimonial que podría experimentar un estafador si su cómplice no le restituye (habiéndolo previamente acordado) los gastos que le demandó consumir el delito.

El “daño resarcible” (“daño-consecuencia”). No se lo ha definido expresamente, lo que seguramente generará muchos contrapuntos, en especial por aquellos que sostienen que las terceras categorías de daños tienen asidero en nuestro ordenamiento.

Sin embargo, entiendo que, pese a ello, la concepción originariamente postulada por Orgaz ha quedado plasmada en el Cód. Civil y Comercial: el *daño resarcible* (esto es, lo que *se indemniza*) *no es la lesión al derecho o al interés, sino las concretas consecuencias perjudiciales de dicha lesión*. La propia Comisión señala la distinción entre el “daño-lesión” y la “indemnización”, como algo *diferente*.

Pero, además, existen varias normas de las que surge con claridad dicha concepción.

En el art. 1726 del Cód. Civil y Comercial se dispone: “Son reparable *las consecuencias dañosas* que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles”. Esta es la norma central. Como puede observarse, lo que se repara (indemniza) no es la lesión, sino las *consecuencias dañosas*. Es clara la separación intelectual de tres momentos causales —valga la expresión— que son sucesivos: el *hecho* que produce un *daño* y que trae aparejadas *consecuencias dañosas*.

En el art. 1738 del Cód. Civil y Comercial se establece: “Indemnización. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances.

Incluye especialmente *las consecuencias* de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”.

Esta última frase es absolutamente coherente con la concepción adoptada, y en nuestra opinión determinante: se identifican y precisan las diversas “lesiones” a derechos e intereses jurídicos, disponiéndose que la indemnización incluye las *consecuencias* derivadas de aquella violación.

Por ende, los derechos personalísimos, la salud psicofísica, el proyecto de vida, etc., no constituyen rubros indemnizables autónomos, sino que lo resarcible son las consecuencias —patrimoniales o extrapatrimoniales— de dichas lesiones.

En el art. 1740 del Cód. Civil y Comercial se hace referencia a los daños *derivados* de la lesión a los derechos personalísimos (el honor, la intimidad y la identidad personal), lo que también importa —de manera coherente con lo anterior— distinguir la lesión del daño resarcible.

El art. 1741 del Cod. Civil y Comercial —referido al daño moral— se titula “indemnización de las consecuencias no patrimoniales”. No se trata, pues, de la reparación de la lesión al interés extrapatrimonial conculcado, sino de sus consecuencias.

En el art. 1745 del Cód. Civil y Comercial surge con claridad que de la muerte de una persona (daño-lesión) pueden surgir múltiples consecuencias, que son las indemnizables (gastos de asistencia y posterior funeral de la víctima, alimentos, pérdida de chances de ayuda futura). Puede observarse, además, que en cada supuesto se brindan las pautas para precisar la indemnización *en el caso concreto*, y no en abstracto o de manera genérica.

De la conjunción de todas estas normas, no puede sino concluirse que el *daño resarcible* (la “indemnización”, en palabras de la Comisión, con la aclaración que hemos efectuado antes) *está constituido por las consecuencias de la lesión, sean patrimoniales o espirituales*.

En efecto, lo que *se indemniza* no es la lesión al derecho o al interés, considerada en sí misma, y que —de hecho— en muchos casos no tiene un valor intrínseco, como sucede con los derechos personalísimos. Además, cuando el bien lesionado tiene un valor económico (por ej., un automóvil),

la sola reparación de su valor puede llegar a ser insuficiente. Por el contrario, se trata de resarcir las *repercusiones de cada lesión*.

Aquí, pues, se trata de un concepto específico, estrictamente técnico, y circunscripto a la *función resarcitoria* de la responsabilidad civil. Como lo señala Zavala de González, “el *daño-resarcible* no puede ser separado de su indemnización. La indemnización requiere un resultado como objeto resarcitorio [...] la noción genérica sobre lesión a un interés es cimiento de esa *daño reparable*, pero debe complementarse con una visión *funcional*. La indemnización es *consecuencia jurídica* — efecto de derecho— de una *realidad fáctica*, equivalente a un menoscabo causado” (Matilde ZAVALA DE GONZÁLEZ, La responsabilidad civil en el nuevo Código. Tomo 2, cit., p. 490).

c.- En relación a lo establecido en el art. 1746 del Cód. Civil, soy de la opinión que no se trata aquí del lucro cesante o de pérdida de chance en concreto, sino de las pérdidas económicas que el suceso dañoso produce (mediando causalidad adecuada) diferentes a dicho lucro cesante, y que se traducen en todos los aspectos de la vida de la víctima en donde la repercusión del hecho dañoso tenga incidencia *económica*.

Esto es: *no es daño moral, sino daño patrimonial que no es alcanzado, o no comprende el estricto lucro cesante de la víctima*.

Es que más allá de una concreta y “efectiva” merma en las ganancias, la pérdida de fuerza productiva, y de la fuerza física en lo que hace a las situaciones cotidianas de la vida necesariamente ha de traducirse en un detrimento económico, en algunos casos de dificultosísima determinación, pero que es indudable que existe: necesitar la ayuda de terceras personas (tiene un costo), no poder desarrollar el trabajo actual con las mismas energías que antes, las mayores dificultades que se experimentan, etc., etc.

Así, y desde la óptica apuntada —y en función al criterio al que adherimos en orden a la clasificación binaria del daño (en patrimonial y moral)-, *el rubro en cuestión integra el daño patrimonial*, correspondiendo —en definitiva- a un daño emergente futuro o a una pérdida de chances productivas, o ambos a la vez, en intrincada interacción y que claramente se “independizan” de

otros daños emergentes futuros (como podría ser un tratamiento psicológico que hay que abonar), o de pérdidas de chances más concretas (por ej., la segura frustración de la chance de un ascenso laboral, ante la incapacidad física). Inclusive, *daños emergentes futuros*.

*Se trata, en definitiva, **de otros daños patrimoniales** que, eventualmente, pueden coexistir con los que surgen con mayor nitidez.*

Aquí entra a tallar una característica esencial para el resarcimiento del daño: este debe ser cierto, esto es, no meramente conjetural o hipotético.

Y debe ser acreditado.

No basta con probar la incapacidad, sino que debe acreditarse su proyección en concreto.

Máxime cuando la incapacidad es de baja intensidad, como es el caso de autos.

Y si bien existe una cierta aleatoriedad en su producción, de todas maneras lo no aleatorio puede acreditarse de manera razonable, a la luz de lo dispuesto en el art. 1744, en relación a que puede tenerse por acreditada la existencia de un daño cuando ello surge **notorio** de los propios hechos: de la disminución psicofísica, sensatamente, y aplicándose las reglas de la sana crítica, podrá concluirse o no en si existe este rubro que ha sido calificado como “incapacidad vital” (por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en el caso “Dutto”, aunque con algunos alcances sutilmente diferentes); y cuál es su entidad cualitativa, para luego poder traducirla en dinero.

Ésta se compone de una suerte de “daño emergente” y además de “pérdida de chances”, causados por dicha incapacidad vital.

En definitiva, este es mi pensamiento sobre el rubro, lo que tampoco se choca con lo dispuesto en el art. 1746 del CCyC: el “daño” a resarcir, no es aquí el lucro cesante. **Repárese que no se dice en la norma que debe indemnizarse “la incapacidad”, sino “el daño”,** y ello dependerá del caso en concreto, interpretando las cosas con la suficiente apertura y flexibilidad, para poder así arribar a una solución de estricta justicia, que no asigne más a la víctima de lo que se le debe, pero tampoco menos de ello. De eso se trata.

d.- El criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El caso “Ontiveros”. En este caso (CSJN, 10/08/2017, “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Ontiveros, Stella Maris c/ Prevención ART S.A. y otros – s/ accidente – inc. y cas.”, Fallos:340:1038), la Corte se aboca a varias cuestiones, y existen algunas sutiles e importantísimas diferencias entre los distintos votos, pero todos tienen algo en común: se fijan varias pautas *conceptuales* que, si bien corresponden al caso en resolución, *no terminan por definir en concreto cuál debería ser el criterio para cuantificar los diversos daños*.

Una oportunidad perdida, en mi opinión, ya que la trascendencia del caso justificaba un fallo sin reenvío.

En orden a lo que ahora nos interesa, esto es, el concepto mismo de *daño*, no existen referencias directas, pero necesariamente subyace el pensamiento de los jueces de la Corte sobre esta cuestión, que constituye el verdadero punto de partida para la resolución del conflicto.

En el *voto mayoritario* se destaca que la indemnización integral por lesiones o incapacidad física o psíquica, “debe reparar la disminución permanente de la aptitud del damnificado para realizar actividad productivas o económicamente valorables”, señalando que ello opera pese a que la víctima continúe desarrollando una tarea remunerada, “pues dicha disminución indudablemente influye sobre las posibilidades que tendría la víctima para reinsertarse en el mercado laboral en el caso que tuviera que abandonar las tareas que venía desempeñando”. Pero, además, con cita de fallos anteriores, se indica que “la incapacidad física del trabajador suele producirle un serio perjuicio en su vida de relación, lo que repercute en su actividad social, deportiva, etcétera; y que ese perjuicio debe ser objeto de reparación al margen de lo que pueda corresponder por el menoscabo de la actividad productiva y el daño moral, *pues la integridad física en sí misma tiene un valor indemnizable*” (el resaltado me pertenece). Concluye que en la sentencia impugnada se debió “valorar desde una perspectiva más amplia la grave afectación a la actividad social y deportiva de la actora que el propio fallo tuvo por probada y examinar, incluso, si las consecuencias del accidente privaron a la magistrada de la posibilidad futura de ascender en su carrera judicial”.

Sin embargo, ninguna pauta más se brindó a los efectos de precisar tan importante toma de posición.

El Dr. Lorenzetti, por su parte, si bien comenzó por reiterar los conceptos antes indicados (además, dejando en claro que ello es lo que se receptó en el Cód. Civil y Comercial), *efectuó una precisión de suma importancia: luego de señalar que el resarcimiento de la incapacidad física “se extiende también a los múltiples ámbitos en que la persona humana proyecta su personalidad integralmente considerada”* (con cita de precedentes de la misma Corte), agregó que *“no se trata, por ende, de resarcir bajo este concepto, una ‘diferencia patrimonial a valores de mercado’, sino de cubrir, lo más fielmente posible, las repercusiones que la alteración de la salud de la actora genera, aún de modo instrumental e indirecto, sobre sus potencialidades o sus otros bienes jurídicos con aptitud para la consecución de beneficios materiales”*.

Es de destacar esta última locución: *“beneficios materiales”*, ya que a renglón seguido desarrolla tal concepción, emplazando la cuestión en el terreno del *daño patrimonial*, indicando que el porcentaje de incapacidad si bien útil no es definitorio ya que hay que valorar las *consecuencias* en el caso concreto, y señalando que *“una reparación eficaz impone la exigencia de abandonar parámetros abstractos –elaborados para un sujeto medio e hipotético- para otorgarle pleno sentido a la reparación del daño conforme a la dimensión concreta de los perjuicios sufridos por la víctima”*.

Trata luego, por separado, lo relativo al daño moral.

Por último, el Dr. Rosenkrantz formuló una *disidencia parcial*. Señaló que en el caso concreto era adecuada la reducción de la indemnización en función de era altamente probable que la actora continúe desempeñando su actividad, pero que de todas maneras la indemnización asignada era insuficiente, pues deben valorarse las proyecciones de la incapacidad *“en el ámbito doméstico, social, cultural y deportivo”*.

En función de las pautas conceptuales que he formulado, en lo que es mi interpretación de la letra del Cód. Civil y Comercial, es clara mi adhesión a lo que el Dr. Lorenzetti indica, ya que *deslinda adecuadamente la cuestión: más allá de la afirmación relativa a que la incapacidad tiene un valor*

por sí misma, lo cierto es que solamente serán resarcibles aquellas proyecciones económicamente disvaliosas, con prescindencia de la cuestión estrictamente laboral.

Se trata, pues, de daño patrimonial, y el Dr. Lorenzetti también parece adherir a la posición de que distingue el “daño-lesión” del “daño-consecuencia”, pues se pronuncia por la reparación de las “repercusiones” en concreto, esto es, en función de las circunstancias que la víctima atraviese, y no de manera abstracta y general.

El voto de la mayoría y de la disidencia genera –peligrosamente- una suerte de “tercer género” al lado del daño patrimonial y el moral, y sin brindar pauta alguna para deslindarlos acabadamente.

En este orden de ideas, PIZARRO advierte –en crítica al voto de la mayoría-: “Esto último nos parece francamente cuestionable, pues trasunta un desenfoque conceptual que hoy puede potenciarse en normas poco depuradas como las que definen el daño y el daño resarcible (bajo el rótulo indemnización) en los arts. 1737 y 1738. El daño resarcible es siempre una consecuencia perjudicial —patrimonial o extrapatrimonial (espiritual)— que deriva de la lesión a un derecho o a un interés. La lesión a la integridad física de una persona no es en sí misma indemnizable, no ser que se proclame que la vida humana y la integridad psicofísica y espiritual tienen un valor económico en sí mismo, independiente de sus repercusiones (daño lesión o daño evento y no daño consecuencia perjudicial), lo cual creíamos que estaba largamente superado en el derecho argentino. Nosotros preferimos interpretar el fallo de la Corte, en este punto, de la siguiente manera: las lesiones a la integridad psicofísica de una persona son indemnizables en cuanto arrojen consecuencias perjudiciales económicas y espirituales, que deben ser calibradas con prudencia y flexibilidad por los tribunales... Lo que no puede hacerse es mandarse a indemnizar el daño patrimonial calibrado con toda dicha amplitud y el daño moral estimado bajo similar perspectiva, y además reconocerse un rubro autónomo por "incapacidad" o "daño a la integridad física en sí misma", que luciría no sólo desajustado conceptualmente, sino reñido con el propio principio de la reparación integral, al condenar a pagar bajo distintos nomen iuris dos veces una misma

indemnización” (Ramón Daniel PIZARRO “El derecho a la reparación integral desde la perspectiva constitucional”, LA LEY 23/08/2017, 6. AR/DOC/2234/2017).

En definitiva, soy de la opinión que lo señalado por el Dr. Lorenzetti es lo que mejor refleja la naturaleza del problema, y brinda una adecuada interpretación (si bien no resulta aplicable al caso) de lo establecido en el Cód. Civil y Comercial, al que cita en su voto, poniendo claramente de manifiesto que lo que el nuevo ordenamiento ha reflejado en esta materia era la opinión imperante al cobijo de la vieja legislación.

4.- El caso de autos.

a.- Como primera medida, debe observarse que si bien la apelante hace referencia en el título de su primer agravio que apela los intereses, finalmente nada dice al respecto, por lo cual cabe descartar tal cuestión.

b.- Ingresando al contenido del agravio en análisis, es dirimente la pretensión contenida en la demanda, en la que, derechamente, y sin mayores precisiones y análisis conceptuales, se cuantifica la incapacidad en sí misma, señalándose de manera expresa que *integridad física tiene por sí misma un valor indemnizable*, tal cual lo ha señalado la Corte.

La cuestión no sólo transita por las bases conceptuales que he señalado previamente, y que hago mías, sino además, en casos como el que nos ocupa (donde se ha acreditado la existencia de una *lesión* a la capacidad vital), establecer cómo debe valorarse el daño resarcible en concreto (esto es, a partir de la *lesión* –daño lesión- determinar su *entidad cualitativa*), y cómo debe luego cuantificarse dicho daño (o sea, traducirse en una suma de dinero).

Lo segundo es aún más dificultoso que lo primero.

b.- En autos, y en relación a lo que es la lesión y sus repercusiones, la sentenciante se ha explayado con profundidad, y ello no ha sido motivo de queja de la apelante:

“Porcentaje de Incapacidad. De la prueba producida, surge acreditado que luego del accidente la Sra. Reyna fue trasladada por el propio chofer de la unidad a la Clínica Caraffa donde fue atendida por el servicio de guardia (cfr. op. 22/02/2022 –Constancia de atención- Pba. Actor-).

Que luego se le ordenó realizarse un IRM de columna Lumbosacra (cfr. op. 29/03/2021- Historia Clínica del Instituto Oulton), en virtud de la cual, atento la “fractura –aplastamiento del cuerpo vertebral D12” se aconsejó “tratamiento de vertebroplastia” (cfr. fs. 12 del pdf. mencionado supra) y que dicho tratamiento efectivamente se realizó con fecha 22/11/2018 (cfr. Historia Clínica del Sanatorio Francés ajunta en pdf. en la op. del 03/08/2021. Pba. Actor).

Además, de dicha prueba informativa surge que en fecha posterior continuó concurriendo al nosocomio a los fines del “control” de la intervención, oportunidad en la que se le indicó fisiokinesioterapia (v. controles de fecha 05/12/18, 04/01/19 y 11/12/19 obrantes en el pdf. correspondiente a la H.C del Hospital Francés).

También obra en autos el dictamen del Dr. Francisco José González (cfr. op. del 14/06/2021), quien, luego de evaluar las constancias médicas de la causa y referidas supra (v. capítulo expositivo), procedió a realizar el examen físico de la actora señalando “Examen Físico. Inspección general: actora lúcida sin disbacia, pulso regular a 75 latidos por minuto, normo-céfalo, visión y audición conservada (permite la comunicación social). Examen sistémico: cabeza y cuello: s/p. Examen de tórax: s/p. Abdomen: s/p. Aparato genito-urinario: sin datos relevantes. Al. Osteo Mio-Articular: masa muscular con tono y trofismo normal para la edad. Columna vertebral: sin desviaciones a la inspección; Columna Cervical: sin contractura muscular ni puntos dolorosos a la palpación; ROM conservado. Columna LS: contractura para-vertebral: (+) derecha e izquierda; movimientos: RD: 30/30°, RI: 30/30°; flexión 75/90°, ID: 20/20°; II: 18/20°; extensión: 20/30°. Lasegue: (-); Maniobra funcional en bipedestación: (-); Lasegue: (-) a 45°. Miembros Inferiores: Fuerza muscular: s/p. Exploración de muslos, piernas y tobillos: s/p; pulsos y reflejos normales; fuerza muscular conservada en MMII; contraresistencia (M5); sensibilidad normal. Examen vascular: normal a la inspección. Evaluación neurológica: sensibilidad y reflejos conservados. El resto del examen no reviste particularidad...”.

Concluye (v. capítulo conclusivo- consideraciones médico legales): “1: La examinada Reyna, Emilia Angélica presenta una secuela de accidente de tránsito que derivó en una fractura

vertebral D12 con resolución quirúrgica (vertebroplastia). 2: Se le determina una incapacidad parcial y permanente del 10% de la T.P según baremo general para el fuero civil Altube-Rinaldi. 3: No presenta sintomatología por la protrusión discal reclamada y hay una alta probabilidad de que la patología discal sea de aspecto degenerativo y puede haberse agravado por el siniestro. 4: La secuela física tenderá a permanecer estable en el tiempo moderado, aunque es posible el agravamiento de su cuadro debido a factores traumáticos, degenerativos entre otros. (...) 6: Pronostico/minusvalía: el impedimento para las tareas de Reyna Emilia Angélica estaría en el hecho de cargar o descargar objetos pesados, principalmente desde niveles cercanos al suelo y sostener posturas forzadas de CLS con frecuencia dentro de su rutina. La actora no puede realizar esfuerzos que profundicen su patología de columna, ya que la misma puede agravarse de someterse a esfuerzos intensos a dicho nivel; por ende ha perdido esa capacidad, en la medida calculada en este informe, y se encuentra limitada para haber tareas habituales que requieran de tales esfuerzos, esto en forma definitiva y para el resto de su vida laboral/cotidiana. Se debe valorar regularmente (mensualmente) la evolución de las lesiones, en este caso dentro de un plan de seguimiento a los fines de decidir las tareas a desarrollar y la carga a soportar que ello implica, siempre de manera gradual. La falta de tratamiento adecuado y el retraso en el mismo pueden hacer que las lesiones reversibles dejen de serlo. De acuerdo a las tareas laborales/cotidianas a desarrollar en el futuro será el impedimento para su desempeño. La necesidad de un nuevo tratamiento reparador quirúrgico no parece necesario en un futuro cercano, aunque esto deberá ser evaluado por el especialista”.

En definitiva, determina una incapacidad del 10 % de la T.P, excluye el porcentaje de incapacidad solicitado por “protusión discal posterior L4/L5” (cfr. certificado Dr. Campillo adjunto en pdf. 1 del 03/07/2020 fs. 2) y efectúa un pronóstico de cómo afectará su patología el desarrollo de las actividades de la vida laborativa/cotidiana.

Dicho informe pericial no fue impugnado por la contraria, por lo que encontrándose debidamente fundado, no identifico mérito alguno para apartarme de sus conclusiones.

Continuando con el análisis de la incapacidad se realiza además examen psiquiátrico por el perito oficial Santiago Bruno Moine (cfr. dictamen del 13/09/2021) quien luego de exponer el relato de la actora en relación al evento dañoso, expresa: “Semiología del comportamiento: ...c) Análisis del comportamiento en el curso de la vida cotidiana: la peritada es independiente para realizar las actividades de la vida diaria, excepto las que le impliquen movimientos forzados (desde lo físico). (...) No ha vuelto a trabajar...”. Semiología de la actividad psíquica basal: a) Claridad e integración del campo de la conciencia y nivel de conciencia: claridad conservada del campo de la conciencia y estado vigil. b) Orientación autosíquica (orientación en persona de sí mismo): conservada. c) Orientación alopsíquica (orientación témporo-espacial) orientado en tiempo y en espacio. d) Atención: euprosia. e) Memoria: memoria de fijación, inmediata y a corto plazo: conservada. Memoria de evocación, a medio y largo plazo: conservada. f) Afectividad: estado de ánimo: eutimia. Emociones: no se objetiva al momento de la entrevista irritabilidad, ni ansiedad, ni angustia. g) Sensopercepción: no se evidencian elementos compatibles con alteraciones de la sensopercepción presentes al momento de la evaluación psiquiátrica y la peritada niega haber presentado alucinaciones. h) Pensamiento: forma o curso: conservada. Contenido: no se evidencia ideas delirantes al momento de la entrevista. Manifiesta preocupaciones en torno a los dolores que presente y al hecho que no ha podido retomar su actividad laboral. i) Lenguaje: Fonación: sin alteraciones significativas. Expresión del lenguaje: no se evidencian dificultades. j) Juicio: comprensión de conceptos: no presenta alteraciones significativas. Logra comprender lo que se le pregunta a lo largo de la entrevista. Relación de conceptos: no presenta alteraciones significativas. Relaciona los elementos de su historia vital sin dificultades. k) Inteligencia: Capacidad de comprender las preguntas: sin alteraciones significativas. Responde a lo que se le interroga de forma adecuada. Capacidad de respuesta: sin alteraciones significativas. Capacidad de Comunicación: conservada, mantiene un diálogo fluido durante el transcurso del examen... ”.

Concluye “la peritada presenta síntomas y/o signos aislados en la esfera psíquica, que no constituyen un trastorno psiquiátrico correspondiente con lo descripto en la clasificación

internacional de enfermedades, en el apartado de psiquiatría (CIE 10ma. Ed. OMS). (...) no se objetiva sintomatología compatible con afección psiquiátrica por lo que no se determina incapacidad. No se objetiva sintomatología compatible con estrés postraumático....”.

Dicho informe no fue impugnado por ninguna de las partes intervinientes, por lo que encontrándose prima facie fundado en principios técnicos del peritaje y no existiendo otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja aceptar el dictamen, pues el perito actúa como auxiliar de la justicia y contribuye con su saber, ciencia y conciencia a esclarecer aquellos puntos que requieren conocimientos especiales.

Definida entonces la incapacidad provocada por el accidente (10% limitada a lo físico, esto es, se excluyó la repercusión psiquiátrica) y su impacto en el desarrollo de sus actividades de la vida cotidiana, corresponde avanzar en el análisis de los elementos de la fórmula”.

d.- En mi opinión, la contradicción de la sentenciante radica en que luego de efectuar un completo e interesante análisis conceptual de la cuestión, haciendo suya la clara descripción efectuada por la perito, termina por calificar el rubro como *perdida de chance* que, verdaderamente, no la hay, y por las mismas razones que ella explicita.

Sin embargo, lo que sí tenemos frente a nosotros es una *clara* lesión a la capacidad vital de la actora, que se prolongará **“en forma definitiva y para el resto de su vida laboral/cotidiana”**, como lo he resaltado con anterioridad. Conclusión a la que se arriba en base a un informe completo, en el que no sólo se describe el origen de la patología y sus características, además de indicarse el porcentual final de incapacidad (que es lo que generalmente ocurre en las pericias que se practican para estos casos), sino que, además, y lo que es **determinante**, la pericia muestra con claridad **las concretas consecuencias y repercusiones de la lesión a la integridad psicofísica en el devenir existencial de la víctima**. Ello es lo que, en concreto, se traduce en el *daño resarcible* mal denominado *incapacidad vital*, ya que se trata de daño resarcible *derivado* de la lesión a la *capacidad vital*.

Sigue, luego de esta determinación cualitativa lo más difícil, que es su *cuantificación*.

Ello es harto dificultoso, en casos como el de autos (en donde, insisto, la entidad *cualitativa* del daño se encuentra cabalmente acreditada), ya que va de suyo que mal podría, a priori, identificarse con una equivocada cuantificación de la “lesión”, en sí misma, partiéndose de la fórmula que se emplea para cuantificar lucro cesante, daño emergente o pérdidas de chance *continuadas*, derivadas de las lesiones a la integridad psicofísicas.

En el caso de autos, es lo recién indicado lo que ha acontecido, y no se han dado pautas básicas para cuantificarlo. Que tampoco las hay en la ley.

La dificultad es casi insuperable, y existe aquí un importante margen de discrecionalidad, que debe partir, naturalmente, de lo indudable de la existencia del daño resarcible mismo, que es lo que se ha probado en la causa.

Para la cuantificación, pues, y siendo que es la propia ley la que carece de pautas a tal fin, el análisis debe comenzar por lo establecido en el art. 1744, que estatuye –en mi opinión- reglas probatorias generales tanto para la valoración (aspecto cualitativo) como para la cuantificación del daño (aspecto cuantitativo), pues allí no sólo no se distingue, sino que no existen razones que permitan limitar dichas reglas generales sólo a la valoración del daño.

Es tal razón de que no resulte la falencia plenamente achacable a la víctima, sino al sistema legal mismo también.

En todo este marco, entiendo que se puede generar **una suerte de piso de daño, en lo cuantitativo, una suerte de punto de partida**, franqueable en función de las circunstancias del caso; y no veo tan equivocado hacerlo desde la aplicación de la fórmula, sobre la base del salario mínimo, y en función del grado de incapacidad en el caso concreto.

Pero **aclaro expresamente, y lo reitero pues deben evitarse malos entendidos**: no se trata de cuantificar el daño cuantificando la incapacidad en sí misma (que es lo que yo objeto, y sin dudarlo), determinándose un monto en abstracto, como se ha hecho tanto en la demanda como en la sentencia, camino que, en mi opinión, es desajustado y distorsivo desde lo conceptual; sino, en los casos de dificultad intrínseca, casi insuperable, para cuantificar este rubro tan particular, tomando

ello como **punto de partida, con una significación diferente**; esto es, no como indemnización de una lesión, sino de un daño resarcible.

Insisto, a falta absoluta de toda otra prueba que permita aportar elementos que habiliten a otra solución.

Y, en función de ese *dato duro*, y de manera prudencial, adaptar la solución al caso concreto.

Así, todo parece indicar que la solución a la que ha arribado la sentenciante es razonable, pero no porque aquí se esté resarciendo pérdida de chances, sino porque aquí se manda a reparar un daño en la capacidad vital de baja entidad cualitativa, que existe con la extensión que se ha determinado.

Y ello –insisto nuevamente- como un piso resarcitorio.

e.- Por ello, y en relación a este agravio, llego a la conclusión de que, en definitiva, corresponde rechazar el recurso de apelación, pero por las razones indicadas en el presente pronunciamiento, manteniendo en todas sus partes lo decidido que, vale aclararlo, no ha sido materia de agravio en cuanto a las variables utilizadas y los cálculos que se han efectuado, sino únicamente en la reducción que la jueza decidiera.

IV.- EL SEGUNDO AGRAVIO.

a.- La Sra. Jueza basó su decisión en la imposición de costas en lo siguiente:

“Teniendo en cuenta que el reclamo iniciado contra Coniferal S.A.C.I.F se admitió parcialmente en su contra, reconociendo íntegramente su responsabilidad; que se demandó por la suma de \$878.610,78 (\$869.980,93 incapacidad vital y \$8629.85 gastos médicos, de farmacia y traslado) y que se condenó por la suma de \$202.304,515 (Pérdida de chance/incap. Vital sobreviviente: \$ 193.674,665 y gastos médicos, farmacia y de traslado: \$8.629,85, que se admitieron ambos rubros aunque el primero parcialmente atento la reducción del porcentaje de incapacidad (en tanto se demandó, consignando como porcentaje 45% y en el dictamen se ponderó 10%). En este sendero, el monto favorablemente acogido equivale al 23% del monto peticionado, estimo prudente distribuir las costas en un 60% a los demandados Coniferal S.A.C.I.F. y Mutual Rivadavia de

Seguros del transporte público de pasajeros y en un 40% al actor, teniendo en cuenta asimismo que litiga con beneficio concedido conforme Expte N° 9279075 (cfr. Auto N° 380 del 21/09/2021) ”.

b.- Como puede observarse, la reducción a la que llega es en razón de la admisión parcial del daño derivado a la lesión de la capacidad vital, desde que el otro rubro (daño emergente por gastos médicos) es admitido en su totalidad.

c.- En relación a las costas, el art. 132 del CPCC reza: *“si el resultado fuese parcialmente favorable para ambas partes, las costas se impondrán prudencialmente en relación con el éxito obtenido por cada una de ellas”*. La pauta básica para medir la imposición de costas es, pues, confrontar el monto de lo demandado con lo obtenido en la sentencia, aunque la misma no es absoluta (Conf. Vénica, Oscar H. *“Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba”*, Ed. Lerner, Córdoba, 1.998, T. II, p. 65).

Existen muchos criterios para la distribución de costas en casos de vencimiento parcial: según algunos, corresponde atribuir las al demandado más allá del resultado final; otros postulan la imposición por el orden causado; también hay quienes sostienen que se debe dejar librado al criterio del juzgador; y finalmente están los que piensan que debe regir el criterio matemático del vencimiento. La Corte Suprema parece inclinarse en estos últimos tiempos por esta última postura: *“es descalificable la imposición de costas en su totalidad a cargo del demandado, si la alzada la fijó atendiendo a que hay que abstraerse de las reclamaciones que no hayan progresado, a la negativa global de la demandada a las pretensiones de la actora y a que la noción de vencido ha de fijarse sin tomar en cuenta los valores aritméticos de las pretensiones y sus resultados, pues estos criterios importan desconocer que fue rechazada la mayor parte de la pretensión dineraria original y que por lo tanto la actora resultó vencida en tal sentido (del dictamen del procurador general que la Corte hace suyo)”* (CSJN, 05/04/2005, *“Sontag, Bruno y otro c. Banco de Galicia y Buenos Aires”*, LL-2005-E-232).

Como bien dice Vénica, en supuestos de vencimiento parcial, *“las costas deben imponerse al demandado en la misma medida en que resultó vencido, y al actor en cuanto su pretensión resultó*

rechazada, todo lo cual surge de comparar el monto de la condena con el monto de la pretensión inicial” (en “Pretensión que prospera parcialmente: costas y honorarios”, LLCba-1987-414).

En mi opinión, corresponde distinguir diversas situaciones.

El punto de partida radica en la existencia de responsabilidad del demandado en el suceso dañoso, con independencia de cuáles hayan sido los daños resarcibles efectivamente causados al actor.

A más de ello, en lo atinente a los rubros resarcitorios, si el actor resulta objetivamente vencido en algún rubro resarcitorio o en todos ellos, por causas que le son exclusivamente imputables, debe cargar con las costas.

Si bien la demanda resarcitoria es una sola, cada uno de los rubros cuyo resarcimiento se solicita constituye una obligación en gran parte independiente una de la otra, si bien comparten un origen genético (causa fuente) común (el hecho dañoso).

Cada una tiene su propia naturaleza (dar o hacer), su propio objeto (puede o no ser dinero, tanto en el caso del daño patrimonial –si alguna reparación se solicita en especie y otras no- y también en el caso del daño moral –si se solicita sólo la publicación de la sentencia-), y hasta su propio plazo de prescripción, eventualmente (por ej., si uno de los daños se produjo *con posterioridad* al suceso dañoso, pero –obviamente- mediando relación adecuada con este último).

Siendo ello así, el actor es quien no sólo debe reclamar su resarcimiento, sino que *debe acreditarlos*. Si bien no es aplicable al caso de autos, en el art. 1744 del CCCN se consagra una regla que es de pura lógica, y que es aplicable al sub lite: el daño debe ser acreditado por quien lo invoca, salvo que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos.

Pues bien, como primera medida debe analizarse si es carga de la víctima probar su propio daño (hecho positivo, por otra parte), si está presumido por la ley (por ej., intereses moratorios), o si surge *in re ipsa* (por ej., daño moral).

A ello cabe agregar otra circunstancia.

Existen rubros en los que la cuantificación inicial (imperativo procesal) es sumamente dificultosa, por cuestiones intrínsecas a la naturaleza del rubro resarcitorio. Un ejemplo

indudable es el daño moral. También en el caso de ciertos daños patrimoniales, en los cuales un cierto grado de incapacidad, u otras cuestiones deben ser definidas por peritos, cuyos criterios científicos pueden variar. De allí la pertinencia de diferir la cuantificación definitiva en estos casos puntuales “*a lo que en más o en menos*” se determine, o según cuál sea el criterio del juzgador.

Pero esto último no debe ser confundido con situaciones en las cuales el pretense acreedor no prueba su daño, o cuando se demuestra que su reclamo excedía los límites razonables de la incerteza intrínseca a la que he apuntado, para ya posicionarse en la categoría de reclamo infundado.

Ello sucede, por ejemplo, si se solicita la indemnización de un daño derivado de una incapacidad, demostrándose luego que el accionante no adolece de incapacidad alguna, siendo ella (así lo suelen decir los peritos) del “cero por ciento (0%)”.

d.- Aplicando tales postulados **al caso de autos**, cabe advertir **la enorme polémica que existe sobre el rubro que ha sido admitido parcialmente**, que ya he señalado y que tengo aquí por reproducida, todo lo cual me lleva a considerar que las costas en la primera instancia deben imponerse en un 100% a la parte demandada y a la citada en garantía, desde que definitivamente no puede negarse que la actora, y también las accionadas, pudieron considerarse con motivos atendibles para sostener jurídicamente las posiciones que postularon.

Por ello, corresponde revocar, en esta parte, la sentencia apelada, imponiendo las costas de la 1ª Instancia a la accionada y a la citada en garantía en un 100%.

Así voto.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DRA. VIVIANA SIRIA YACIR DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones a los que arriba el señor Vocal del primer voto, en consecuencia, voto en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DR. FEDERICO ALEJANDRO OSSOLA, DIJO:

Por todo lo expuesto, en mi opinión corresponde:

I.- Tener presente y admitir el desistimiento de la demandada CONIFERAL S.A. y la Citada en Garantía MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS del recurso de apelación interpuesto por ambas en contra de la Sentencia N° 191 del 30/10/2022 dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia y 12° Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad. Sin costas.

II.- Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, Sra. Emilia Angélica REYNA, revocando la imposición de costas decidida en la 1° Instancia, imponiendo las costas de dicha instancia en un cien por ciento (100%) a la parte demandada CONIFERAL S.A. y a la Citada en Garantía MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS; rehazándolo en todo lo demás que ha sido materia de agravio.

III.- Imponer las costas del recurso de apelación por el orden causado, atento a que ambas partes pudieron considerarse (por lo señalado respecto a las costas de la 1° Instancia) con motivos atendibles para litigar, en ambos agravios.

IV.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Pablo Nicolás QUIROGA –Abogado de la apelante- en el 30% del término medio de la escala del art. 36 de la ley 9459, sobre lo que ha sido motivo de agravio, sin perjuicio del mínimo de 8 Jus y con más IVA si al tiempo del pago reviste la condición de Inscripto ante la AFIP.

V.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Marcelo MONTENEGRO –Abogado de la demandada CONIFERAL S.A.- en el 30% del término medio de la escala del art. 36 de la ley 9459, sobre lo que ha sido motivo de agravio, sin perjuicio del mínimo de 8 Jus y con más IVA si al tiempo del pago reviste la condición de Inscripto ante la AFIP.

VI.- NO regular honorarios profesionales al abogado de la citada en garantía, atento a que su actividad en el recurso de limitó a la mera adhesión a la contestación efectuada por la demandada.

Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DRA. VIVIANA SIRIA

YACIR DIJO:

Adhiero a los fundamentos y conclusiones a los que arriba el señor Vocal del primer voto, en consecuencia, voto en idéntico sentido.

Por todo ello, y lo dispuesto por el art. 382 del CPCC,

SE RESUELVE:

I.- Tener presente y admitir el desistimiento de la demandada CONIFERAL S.A. y la Citada en Garantía MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS del recurso de apelación interpuesto por ambas en contra de la Sentencia N° 191 del 30/10/2022 dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia y 12° Nominación en lo Civil y Comercial de esta Ciudad. Sin costas.

II.- Admitir parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, Sra. Emilia Angélica REYNA, revocando la imposición de costas decidida en la 1° Instancia, imponiendo las costas de dicha instancia en un cien por ciento (100%) a la parte demandada CONIFERAL S.A. y a la Citada en Garantía MUTUAL RIVADAVIA DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS; rehazándolo en todo lo demás que ha sido materia de agravio.

III.- Imponer las costas del recurso de apelación por el orden causado.

IV.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Pablo Nicolás QUIROGA –Abogado de la apelante- en el 30% del término medio de la escala del art. 36 de la ley 9459, sobre lo que ha sido motivo de agravio, sin perjuicio del mínimo de 8 Jus y con más IVA si al tiempo del pago reviste la condición de Inscripto ante la AFIP.

V.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Marcelo MONTENEGRO –Abogado de la demandada CONIFERAL S.A.- en el 30% del término medio de la escala del art. 36 de la ley 9459, sobre lo que ha sido motivo de agravio, sin perjuicio del mínimo de 8 Jus y con más IVA si al tiempo del pago reviste la condición de Inscripto ante la AFIP.

VI.- No regular honorarios profesionales al abogado de la citada en garantía por sus tareas en este recurso, atento lo indicado en el Considerando pertinente.

PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y BAJEN.